

1500442-06.2020.8.26.0578

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... condenatório e, quanto ao crime de tráfico, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4ª, da Lei n.º 11.343/06. Em relação ao réu DIOGO, no mérito, requereu a sua absolvição da acusação pela prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, sob o fundamento de insuficiência de provas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500442-06.2020.8.26.0578 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500442-06.2020.8.26.0578

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado

JOSE GOMES DA CUNHA NETO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

JOSÉ GOMES DA CUNHA NETO e DIOGO GABRIEL CORREIA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, cumulados com o artigo 40, inciso III, todos da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 24 de outubro de 2020, às 15h30min, na Rua Álvaro Doriguelo, n.º 98, no Jardim Anchieta, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, os réus se associaram para a prática do crime de tráfico, bem como guardavam, para fins de tráfico, duas pedras - com massa de 0,1 grama - de crack, quatro tijolos - com massa total de 3564,9 gramas - de maconha, duas porções - com massa de 3,4 gramas - da mesma substância entorpecente e uma porção - com massa de 398,07 gramas - de cocaína, todas substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Os réus foram notificados (fl. 165) e o defensor constituído apresentou as defesas preliminares (fls. 154/159 e 160/162).

A decisão de fls. 172/173 recebeu a denúncia, no dia 14 de janeiro de 2021.

Os réus foram regularmente citados.

Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas comuns e cinco de defesa e os réus foram interrogados.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação dos réus nos termos das imputações contidas na denúncia. A defesa suscitou preliminar de nulidade decorrente da entrada ilegal dos policiais

militares na residência de cada um dos réus sem autorização judicial e, no mérito, em relação ao réu JOSÉ, requereu a sua absolvição da acusação pela prática do crime de associação para o tráfico, sob o fundamento de insuficiência de provas a justificar um decreto condenatório e, quanto ao crime de tráfico, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4^a, da Lei n.º 11.343/06. Em relação ao réu DIOGO, no mérito, requereu a sua absolvição da acusação pela prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, sob o fundamento de insuficiência de provas de sua autoria a justificar um decreto condenatório.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A alegação de nulidade do flagrante decorrente da entrada ilegal dos policiais militares na casa de cada um dos réus não merece acolhimento.

Considera-se que no Brasil não existem direitos absolutos.

O princípio da proporcionalidade – que deve orientar o intérprete na escolha da opção legal que cause o menor prejuízo coletivo – impõe a conclusão de que, no caso concreto, o interesse da sociedade na segurança pública prevalece sobre o direito individual à preservação da intimidade.

A entrada dos policiais militares na casa de JOSÉ estava autorizada pela sua visualização da entrada de DIOGO levando a mala e de sua saída do imóvel sem a mala – o que permitia concluir que a droga estava na casa de JOSÉ –, e a entrada dos policiais militares na casa de DIOGO estava autorizada por se tratar da pessoa que havia sido vista entrando na casa de JOSÉ levando a mala e saindo sem ela.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 foram inequivocamente demonstradas e ensejam a condenação dos réus.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, conjugado com os laudos de constatação provisória de fls. 26/28 e com os laudos de exame químico-toxicológicos de fls. 170/171.

A autoria, por sua vez, decorre das declarações dos réus, do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo, o réu JOSÉ confessou a prática do crime de tráfico e negou a coautoria de DIOGO, bem como a associação. Disse que estava no quintal usando uma pedra de crack quando ouviu sua companheira conversando alto dentro de casa e constatou que os policiais militares já estavam lá dentro. Narrou que afirmou que não tinha mais droga na casa e disse que foi agredido quando os policiais militares encontraram a mala contendo os quatro tijolos de maconha. Afirmou que a porção de cocaína estava dentro da mala, junto com a maconha. Disse que havia pego as substâncias entorpecentes para vendê-las uns dois ou três dias antes, porque estava passando por dificuldades financeiras, mas que não chegou a fazê-lo. Inquirido pelo representante do Ministério Público por que não escondeu as substâncias entorpecentes, respondeu que estava pensando em devolvê-las. Afirmou que foi coagido pelos policiais militares a dizer que as substâncias entorpecentes eram de DIOGO, o que não era verdade, mas que cedeu à coação porque acreditou na ameaça de que a sua companheira seria presa. Disse que não conhecia DIOGO e que não tinha nenhum relacionamento com ele.

Por sua vez interrogado, o réu DIOGO negou a prática dos crimes cuja autoria lhe foi imputada. Afirmou que estava no quintal de sua casa e disse que havia acabado de vender duas camisetas, uma bermuda e um boné para a testemunha Paulo. Narrou que os policiais militares abriram o portão e já o algemaram, e quando lhes perguntou a razão, eles retiraram o baseado que trazia preso à orelha e lhe disseram que era por aquilo. Afirmou que foi levado para a delegacia e que somente lá, depois de um tempo e já na presença do seu advogado, foi informado de que estava sendo acusado de ser o proprietário das drogas apreendidas na casa do corréu, que afirmou não conhecer.

A negativa dos réus quanto à conduta de DIOGO não foi corroborada pelos demais elementos de prova dos autos.

Os policiais militares Carlos Alexandre Cornélio e Cristiano Ribeiro de Camargo

afirmaram que receberam denúncia de que o réu DIOGO, conhecido nos meios policiais como sendo um grande traficante da cidade, levaria droga para a residência do réu JOSÉ, local que utilizava para guardar droga. Disseram que os policiais militares Herrera e Teixeira ficaram nas imediações da residência de JOSÉ e viram quando DIOGO chegou em uma motocicleta, trazendo uma mala grande, e entrou no imóvel. Narraram que foram contatados pelos policiais que realizavam a campana e se dirigiram imediatamente ao endereço, mas que quando chegaram DIOGO já tinha saído da casa e ido embora sem a mala. Disseram que JOSÉ estava em frente da casa e lhes franqueou a entrada. Afirmaram que localizaram em um dos quartos a mala com quatro tijolos de maconha, bem como, também no quarto, mas em uma cômoda, uma balança de precisão, embalagens plásticas e uma embalagem com uma porção grande de pasta-base de cocaína. Afirmaram que JOSÉ disse que guardava a droga para DIOGO e recebia R\$500,00 por mês. Disseram que na sequência foram à residência de DIOGO, que também foi preso em flagrante.

O policial militar João Paulo Teixeira dos Santos afirmou que receberam uma denúncia de que DIOGO entregaria droga a JOSÉ, que a estava guardando para ele. Disse que permaneceu com o PM Herrera em uma viatura descaracterizada nas imediações da residência de JOSÉ e que visualizaram quando DIOGO chegou em uma motocicleta preta e desceu do veículo com uma mala e entrou na casa de JOSÉ. Narrou que acionou os policiais militares da outra guarnição, mas que antes de eles chegarem DIOGO saiu da casa e foi embora. Afirmou que, assim que as demais viaturas chegaram, abordaram JOSÉ, que estava na frente da casa usando crack. Disse que perguntaram se havia mais droga e que ele respondeu que não, mas autorizou a sua entrada. Narrou que conversaram também com a companheira do réu, Luana, que também autorizou a entrada. Afirmou que no closet localizaram a mala, que era idêntica à mala com a qual DIOGO havia entrado na casa e dentro da qual havia quatro tijolos de maconha. Disse que, em uma cômoda, foram localizadas uma balança de precisão e uma porção significativa de cocaína. Narrou que tanto JOSÉ como Luana afirmaram que recebiam aproximadamente R\$500,00 de DIOGO para guardar a droga para ele. Afirmou que na sequência foram à casa de DIOGO, onde ele estava usando maconha e tinha consigo R\$170,00 em dinheiro, mas nada mais de ilícito foi localizado. Disse que a mãe do réu e outras pessoas estavam no local e começaram a se aglomerar, razão pela qual optaram por não fazer nenhuma diligência na residência e o levaram diretamente à Central de Polícia Judiciária. Narrou que a autoridade policial os questionou sobre a apreensão da motocicleta e que os policiais que voltaram à casa não localizaram mais o veículo.

Quanto às declarações dos policiais militares, especificamente sobre a denúncia anterior de que DIOGO levaria a droga e sobre a visualização da entrada de DIOGO na residência de JOSÉ levando a mala que posteriormente foi localizada nesse imóvel, é de rigor a conclusão de que são dignas de credibilidade.

Nesse sentido:

“PROVA – DEPOIMENTO POLICIAL – Alegação de contraditoriedade e ausência de valor probante. Insubsistência. Depoimentos de policiais obedecem aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não se podendo cogitar de suspeição ou inidoneidade. Precedentes. Recurso improvido para este fim” (TJSP – Apelação Criminal n.º 439.373-3/9 – Origem: São Vicente – Relator: Des. Marcos Zanuzzi – J. 16.03.2006).

É pacífico que o depoimento do policial tem o mesmo valor do depoimento de qualquer outra testemunha, já que prestado sob as mesmas condições.

A propósito:

“O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta corte. II. Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em outros elementos de prova, tais como a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada e a existência de embalagens usualmente destinadas à preparação do entorpecente para a venda. III. Recurso desprovido” (STJ – RESP 200500786783 – (751760 MG) – 5ª T. – Rel. Min. Gilson Dipp – DJU 14.11.2005 – p.

00400).

Inexistindo qualquer indício de que tenham qualquer interesse em incriminar falsamente o réu, seu depoimento merece crédito assim como o de qualquer outra testemunha.

Nesse sentido, inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS – O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal – O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73518 – Relator: Min. Celso de Mello – 1ª Turma – J. 26/03/1996).

No caso concreto, inexistem elementos, sequer indícios de que os policiais militares pretendessem prejudicar os réus, mas sim de que apenas cumpriam o seu dever funcional.

A testemunha Luana Teodoro Rodrigues da Cunha afirmou que é companheira de JOSÉ e disse que no dia dos fatos os policiais militares pularam o muro de sua casa e o abordaram, exigindo que lhes dissesse onde estava a droga. Narrou que o réu disse que não tinha droga, mas que na sequência os policiais militares localizaram a droga, que (a testemunha) não sabia que estava na casa. Afirmou que os policiais militares lhe apresentaram uma balança e disseram que tinha resquícios de drogas, o que não era verdade, porque era utilizada pelo réu para fazer o pão que vendia nas ruas.

A testemunha Rosimara afirmou que conhece o réu JOSÉ há oito anos e disse que tem conhecimento de que ele trabalhava vendendo pão na rua. Narrou que tem conhecimento de que ele foi internado algumas vezes em razão do vício.

A testemunha Amanda afirmou que conhece JOSÉ há oito ou nove anos e disse que a profissão dele é padeiro. Narrou que sabe que é ele usuário de drogas, mas que pelo que sabe ele tinha uma vida normal quando não estava sob o efeito da droga.

A testemunha Paulo afirmou que no dia dos fatos comprou de DIOGO algumas peças de roupas e um boné e pagou a ele R\$170,00 em dinheiro. Disse que havia acabado de pagar o réu e estava no quintal quando os policiais militares abriram o portão e entraram de repente e já algemaram o réu. Narrou que os policiais verificaram a sua sacola, que continham as roupas, e que na sequência o liberaram.

A testemunha Angelica afirmou que é vizinha e disse que estava com a mãe dele e as crianças, na frente da casa dele, quando os policiais militares chegaram. Narrou que tentou filmar a operação policial, mas que os policiais lhe disseram que era proibido e inclusive o PM Alexandre disse que a levaria presa em razão dessa sua conduta.

As declarações dessas testemunhas não alteram os fatos narrados pelos policiais militares e consistentes na entrada de DIOGO na casa de JOSÉ levando a mala contendo a maconha e que foi posteriormente localizada nesse imóvel.

Assim é que, em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável o acolhimento da tese que pretende a descaracterização da conduta de tráfico praticada por DIOGO.

Quanto aos valores em dinheiro apreendidos com os réus, tendo em vista a ausência de comprovação de exercício de qualquer atividade lícita e a localização das substâncias entorpecentes nas circunstâncias retro referidas, é de rigor a conclusão de que eram provenientes do crime de tráfico, razão pela qual deve ser decretado o seu perdimento em favor da União.

Por outro lado, quanto ao crime de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06, embora existam indícios, não há provas estremes de dúvida de que se tenha verificado.

O vínculo associativo é a figura central do tipo penal do artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006, e deve ficar comprovado de forma cabal, o que enseja a conclusão de que o mero concurso não basta à tipificação dessa conduta. Ou seja, para a

caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas, é imprescindível que os agentes pratiquem a conduta em liame subjetivo com a finalidade permanente de tráfico de drogas, de maneira estável e rotineira, o que não se verificou no caso concreto.

Embora o representante do Ministério Público afirme que uma única conduta pode caracterizar a associação, trata-se de situação a ser muito bem delineada, sendo entendimento deste juízo a necessidade de caracterização ao menos da intenção de estabilidade e permanência.

No caso concreto, embora os policiais militares tenham afirmado que JOSÉ e a sua companheira afirmaram que estavam guardando droga para DIOGO havia alguns meses, essa prova não foi corroborada em juízo, razão pela qual não pode ser considerada para a caracterização do crime de associação.

Ou seja, embora seja possível que os réus tenham se associado, não se pode afirmar de forma estreme de dúvida que o tenham, já que a prova produzida não autoriza a concluir nada além da simples coautoria e impede a condenação dos réus pelo crime previsto no artigo 35, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Provas da materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelos réus JOSÉ GOMES DA CUNHA NETO e DIOGO GABRIEL CORREIA DE OLIVEIRA, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Passo à aplicação de suas penas.

Em relação ao réu JOSÉ, em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Embora a quantidade das substâncias entorpecentes seja elevada, considera-se que o réu estava guardando para DIOGO, razão pela qual não se justifica o aumento da pena-base sob esse fundamento.

Em segunda fase, considero a agravante da reincidência (Processo n.º 0001501-36.2017.8.26.0408, desta Vara, na certidão de fls. 69/70) compensada com a atenuante da confissão e mantenho a pena no mesmo patamar.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento e de diminuição.

Tratando-se de reincidente (certidão de fls. 69/70), inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista a conclusão inequívoca de sua dedicação reiterada a atividades criminosas.

Em relação ao réu DIOGO, em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Justifica-se a fixação da pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal em razão da quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas.

Em segunda fase, considero a agravante da reincidência (Processo n.º 0006259-58.2017.8.26.0408, desta Vara, na certidão de fls. 74/76) e da reincidência específica Processo n.º 0001213-59.2015.8.26.0408, da 2ª Vara Criminal local, na certidão de fls. 74/76) e, sob tal fundamento, aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento e de diminuição.

Tratando-se de reincidente específico (Processo n.º 0001213-59.2015.8.26.0408, da 2ª Vara Criminal local, na certidão de fls. 74/76), inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista a conclusão inequívoca de sua dedicação reiterada a atividades criminosas e especificamente à atividade criminosa do tráfico.

A pena privativa de liberdade imposta a cada um dos réus será cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 20, § 10, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07), observados os critérios legais para a progressão de regime de acordo com a situação de cada um dos ora condenados (artigo 20, § 20, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07).

Os réus não poderão apelar em liberdade. Considera-se que foram presos em flagrante

e permaneceram presos durante todo o processo, o que demonstra a existência do fumus boni iuris, que, com a prolação desta sentença, tornou-se evidente. A manutenção da prisão tem por fundamento a garantia da ordem pública, já que os réus, que são reincidentes (certidões de fls. 69/70 e 74/76), foram novamente condenados pela prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, que sustenta o crime organizado e é responsável pelo estímulo à prática criminosa. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal.

I - CONDENO:

I.1 - O réu JOSÉ GOMES DA CUNHA NETO, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o no estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido.

I.2 - O réu DIOGO GABRIEL CORREIA DE OLIVEIRA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 777 (SETECENTOS E SETENTA E SETE) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o no estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido.

Para fins de proibição do benefício do livramento condicional, nos termos do artigo 44, parágrafo único, da Lei n.º 11.343/06 ("Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico"), fica consignado que o réu DIOGO é reincidente específico (fls. 74/76).

II - ABSOLVO os réus JOSÉ GOMES DA CUNHA NETO e DIOGO GABRIEL CORREIA DE OLIVEIRA da acusação pela prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei n.º 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União dos valores em dinheiro apreendidos nos autos (fls. 14/15). Após o trânsito em julgado, oficie-se à SENAD e se proceda ao necessário para a sua transferência ao FUNAD.

Quanto aos demais objetos apreendidos nos autos (fls. 14/15), tratando-se de objetos relacionados ao crime de tráfico, determino o seu encaminhamento para destruição também após o trânsito em julgado.

P.I.C.

Ourinhos, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA